

令和7年（行ウ）第20号、同第32号 地位確認等請求事件

原告 株式会社長澤薬品ほか2名

被告 国（処分行政庁 厚生労働大臣）

準備書面（3）

令和7年12月16日

東京地方裁判所民事第38部B1係 御中

被告指定代理人	志	水	崇	通
	小	西	俊	輔
	渡	邊	正	幸
	後	藤	優	太
	大	原		拓
	松	岡	克	朗
	山	下	雄	大
	中	村	早	希
	末	永	朝	美
	内	田	成	美

小	野	雅	世
西	村	美	鈴
山	本		剛
岩	瀬		怜
阿	部		讓
篠	原	太	一
澤	本	美	穂
平	田	優	佳
数	井	駿	兵

(目 次)

第 1	訴えの追加的変更申立書(2)に対する答弁等.....	4
1	「追加する請求の趣旨」に対する答弁.....	4
2	「予備的請求に係る請求の原因」に対する認否及び被告の主張	4
(1)	認否.....	4
(2)	被告の主張.....	4
第 2	原告ら第 3 準備書面に対する反論.....	5
1	本件広告等地位確認の訴えには確認の利益がある旨をいう原告らの主張は理由がないこと(原告ら第 3 準備書面第 1 に対する反論).....	5
(1)	原告らが主張する行政指導の存在又は内容は、本件各通知に外部効果が認められることを基礎づける事情とはなり得ないこと.....	5
(2)	原告らが具体的に指摘する行政指導等は、いずれも対象とされた薬局毎の個別的要因を踏まえた適切かつ妥当なものであること.....	6
(3)	原告まゆみ薬局及び原告グランドヘルスのホームページに係る原告らの追加主張は理由がないこと.....	14
2	処方箋医薬品以外の医療用医薬品につき、薬局においては処方箋に基づく薬剤の交付が原則となることは、法令の趣旨を踏まえた解釈であること(原告ら第 3 準備書面第 2 に対する反論).....	16
(1)	薬局医薬品から薬局製造販売医薬品を除いた医薬品(＝医療用医薬品)は、薬剤師の判断により販売することができない医薬品であること.....	16
(2)	薬局医薬品から薬局製造販売医薬品を除いた医薬品(＝医療用医薬品)を処方する行為は、「医行為」に該当すること.....	19
第 3	結語.....	21

被告は、本書面において、原告らが令和7年10月24日付け訴えの追加的変更申立書(2)(以下「**訴えの追加的変更申立書(2)**」という。)で追加した請求の趣旨に対する答弁等をするとともに(後記第1)、同日付け原告ら第3準備書面(以下「**原告ら第3準備書面**」という。)に対して必要な範囲で反論する(後記第2)。

なお、略語等は、本書面で新たに定めるもののほか、従前の例による。

第1 訴えの追加的変更申立書(2)に対する答弁等

1 「追加する請求の趣旨」に対する答弁

- (1) 原告らの請求を棄却する
 - (2) 訴訟費用は原告らの負担とする
- との判決を求める。

2 「予備的請求に係る請求の原因」に対する認否及び被告の主張

(1) 認否

- ア 第2の1ないし5は答弁書に記載のとおり。
- イ 第2の6(1)ないし(4)は認否の限りでない。
- ウ 第2の6(5)及び(6)並びに第3は争う。
- エ 第2の7は然るべく。

(2) 被告の主張

被告準備書面(1)第1の4(4)イ(29ページ)及び被告の令和7年10月31日付け準備書面(2)(以下「**被告準備書面(2)**」という。)第1の2(2)ウ(6及び7ページ)で述べたとおり、薬機法のみならず、医師法等の関係する法律の仕組みを全体として見た場合において、「やむを得ず販売を行わざるを得ない場合でなくとも(中略)医師の受診勧奨を行うことなく、処方箋医薬品以外の医療用医薬品の分割販売を行うことのできる地位」自体を認める余地がないから、訴えの追加的変更申立書(2)に係る原告らの請求は理由がない。

第2 原告ら第3準備書面に対する反論

- 1 本件広告等地位確認の訴えには確認の利益がある旨をいう原告らの主張は理由がないこと(原告ら第3準備書面第1に対する反論)

- (1) 原告らが主張する行政指導の存在又は内容は、本件各通知に外部効果が認められることを基礎づける事情とはなり得ないこと

ア 原告らの主張

原告らは、本件店舗(池袋セルフメディケーション)に対する執拗な行政指導があったなどと繰り返すほか、原告ら以外の「零売」を営む薬局に対しても行政指導が行われているなどとして、本件各通知は「地方公共団体に対する技術的指導(マ)を超え」るものであり、外部効果を有する旨を主張するようである(原告ら第3準備書面・1ないし3、6ないし9ページ)。

イ 被告の反論

本件広告等地位確認の訴えにおける主たる審理・判断の対象は、当該訴えが、原告らの権利ないし法律上の地位に生じている現実的な危険や不安を除去するために有効かつ適切な手段であるといえるか否かの法的評価・法的判断である。

しかるに、被告がこれまで繰り返し述べているとおり、本件各通知の法律上の位置づけが技術的助言(地方自治法245条の4第1項)であることは明白であるところ、これを受けた都道府県等において、本件各通知に従って事務を処理しなければならない法律上の義務を課するものではないという法的な仕組みに照らせば、本件各通知には外部効果が認められないのであるから(被告準備書面(1)第3の1・35及び36ページ参照)、本件広告等地位確認の訴えが、原告らの権利ないし法律上の地位に生じている現実的な危険や不安を除去するために有効かつ適切な手段であるとはいえない。原告らは、「零売薬局」(「零売」を主たる業態とする薬局をいう。以下同じ。)に対する行政指導の内容等について種々主張するが、行政

指導が任意性を前提とした事実行為にすぎないものであることからすれば、本件各通知を根拠とした行政指導の有無やその指導内容は、技術的助言にすぎない本件各通知に外部効果が認められることを基礎づける事情とはなり得ないというべきである。

また、この点をおくとしても、原告らが具体的に指摘する行政指導は、いずれも対象とされた薬局毎の個別的要因に起因するものであるから、かかる行政指導の内容等をもって、本件各通知に一般的な外部効果が認められる旨をいう原告らの主張には論理の飛躍があるし、被告準備書面(2)第2の1(2)イ(8ページ)で述べたとおり、仮に本件広告等地位確認の訴えに係る請求が認められたとしても、処方箋医薬品以外の医療用医薬品に関して、原告らが本件各通知に基づく行政指導を受け得ることには変わりがないのであるから、いずれにしても、原告らの指摘する行政指導がなされたことをもって、本件広告等地位確認の訴えが、原告らの権利ないし法律上の地位に生じている現実的な危険や不安を除去するために有効かつ適切な手段であるとは評価できない。

したがって、原告らの前記アの主張は理由がないものであるが、念のため、原告らが具体的に指摘する行政指導等は、いずれも対象とされた薬局毎の個別的要因を踏まえた適切かつ妥当なものであり、原告らが営む薬局の広告活動に何ら不利益を与えるものでもないことを、項を改めて詳述する。

(2) 原告らが具体的に指摘する行政指導等は、いずれも対象とされた薬局毎の個別的要因を踏まえた適切かつ妥当なものであること

ア 池袋保健所の行政指導に係る原告らの主張には理由がないこと

(7) 原告らの主張

原告らは、「平成29年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況」(甲23)における薬局に対する個別指導件数に比して本件店舗

に対する行政指導件数が過剰であることや、原告長澤薬品の代表取締役が開設した保険調剤薬局のうち「零売薬局」である本件店舗以外に対しては、定期立入検査以外の立入検査が実施されていないこと等を挙げて、本件各通知に基づき、「零売薬局」を狙い撃ちにした極めて執拗な行政指導が行われていたと主張する(原告ら第3準備書面・1ないし3ページ)。

(イ) 被告の反論

a この点、原告らが挙げる甲第23号証は、医療保険制度の中で、保険医療機関等(保険医療機関及び保険薬局の総称)に対して各地方厚生局が行う保険制度の観点からの指導・監査に関する資料であるところ、その「個別指導」の件数はいずれも、「保険診療・保険調剤の質的向上及び適正化を図ることを目的として、療養担当規則等に定められている診療方針、診療報酬・調剤報酬の請求方法、保険医療の事務取扱等について周知徹底する」(甲23・7ページの「Ⅱ 指導関係」、「1 指導」欄参照)ために、健康保険法並びに保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則に則って行われる保険請求の適正性を指導・監査する目的で実施されるものの件数にすぎない。すなわち、同号証の「個別指導」の件数は、保健所等が薬機法等の公衆衛生の観点から実施する監視指導とは、何ら関係がない件数であるところ(例えば、同号証4及び5ページで言及されている事例は、いずれも診療報酬等の不正請求、不当請求又は過誤請求に関するものである。)、薬局に対する行政指導の実施状況に係る原告らの認識には誤りがあるから、かかる誤った認識を前提とした原告らの主張には理由がない。

b また、原告らは、原告長澤薬品の代表取締役が本件店舗以外に保険調剤薬局7店舗を開設したことを前提とした主張をするが、そもそも原告ら自身がいずれの薬局について言及しているかを明らかにしないため、被告において的確な反論を行うことが困難である。

立入調査及び行政指導を行っているが、基本的に当該指導等は本件各通知とは関係のない、上記各店舗における薬機法違反の通報や調査を行った結果発覚した薬機法違反の事象(薬局医薬品がインターネット販売されていたことや、無許可での医薬品の小分け製造がされていたこと)を受けての対応にすぎない。

(b) また、甲第30号証に記載された令和5年12月17日の行政指導は[REDACTED] ([REDACTED])

[REDACTED]に対するものである。原告らは、薬事監視指導票(甲30)を挙げて、上記行政指導が令和4年通知に基づく指導であったことを強調するようであるが、当該行政指導においては、許可更新時の実地検査を端緒として、インターネット上の広告表現に関して不適切であることを指摘したにすぎず、その実施態様も適切な行政指導の範囲内で行われたから、「執拗な行政指導」であるとする原告らの主張を根拠づけるものではない。

b なお[REDACTED]、前記の各行政指導を受けたにもかかわらず[REDACTED]のホームページや各店舗の店頭看板等において、以下のように一般消費者を対象として、処方箋なしに処方箋医薬品以外の医療用医薬品を販売できることを積極的に広告していることを、念のため付言する。

- ① ホームページの検索結果の大見出しに、「処方せんなしで病院の薬が買える薬局」と表示されるようにしている(乙28の1)。
- ② ホームページのトップページ等において、処方箋なしで医療用医薬品を購入できること、病院にいかなくても医療用医薬品が購入できること、時間の節約になること、病院にかかるよりも値段が安く済むこと等を積極的に説明している(乙28の2、乙28の3)。

③ 店頭看板において、処方箋なしで医療用医薬品を購入できることを積極的に説明している(乙28の4)。

(イ) ■■■■■ に対する行政指導について

a 以下に述べるとおり、大阪市健康局■■■■■開設する■■■■■
■■■■■に対して行った行政指導は、主として、当該薬局の開設時における前提となる説明内容に齟齬があり、事実関係を明らかにする必要があることから行ったものにすぎず、単に当該薬局が「零売薬局」であることを理由としたものではない上、その実施態様も適切な行政指導の範囲内で行われたものであるから(乙29)、「執拗な行政指導」が行われたとして本件各通知に外部効果がある旨をいう原告らの主張を根拠づけるものではない。

(a) すなわち■■■■■(大阪市中心部)は平成29年に開設されたところ、開設に先だって、当該薬局に「処方箋なしで病院の薬が買える」という内容の看板が設置されている旨の通報があったことから、大阪市健康局において、真偽を確認するために、同年1月25日■■■■■との面談を実施した。その結果、当該薬局において「零売はやる予定はない。」という説明がなされたため、大阪市健康局としても、零売をしないのであれば「処方箋なしで病院の薬が買える」という看板は不要ではないかと質問したところ、■■■■■
■■■■■側から当該看板の撤去に応じる意向を確認した。大阪市健康局は、以上の点を確認する趣旨で薬事監視指導票(甲32)を交付し、
■■■■■側から任意で誓約書(甲33)の提出を受けたものである。

(b) また、大阪市健康局は、前記面談後、■■■■■に対し、平成29年5月までの間に合計10回の行政指導等を実施したが、これは、前述した経緯で「零売」をせず、看板は撤去するという説明が

あったにもかかわらず、実際には「零売」を行い、看板の撤去もされていなかったという事実を把握したことから、従前受けた説明内容との齟齬を確認する目的で行われたものであって、その実施態様も適切な行政指導の範囲内で行われたにすぎない。

b なお[]は、前記の各行政指導を受けたにもかかわらず、同薬局のホームページや店頭看板等において、以下のように一般消費者を対象として、処方箋なしに処方箋医薬品以外の医療用医薬品を販売できることを積極的に広告していることを、念のため付言する。

- ① ホームページの検索結果の見出しに、「処方せんなしで病院の薬が買える零売薬局です」と表示されるようにしている(乙30の1)。
- ② ホームページのトップページ等において、医療用医薬品が病院に行かずとも直接買えること等を積極的に説明している(乙30の2)。
- ③ 店頭看板において、処方箋なしで医療用医薬品を購入できることを積極的に説明している(乙30の3)。

(ウ) []に対する行政指導について

a 以下に述べるとおり、埼玉県加須保健所が[]の開設する[]に対して行った行政指導は、埼玉県が当該店舗に関して受け付けた通報を端緒として、これに対応するために行われたものであり、[]が「零売薬局」であることを理由としたものではない上、その実施態様も適切な行政指導の範囲内で行われたものであるから(乙31)、「執拗な行政指導」が行われたとして本件各通知に外部効果がある旨をいう原告らの主張を根拠づけるものではない。

すなわち[]は令和7年5月に埼玉県加須市で開設されたところ、開設に先だって市民から、当該薬局において医療用医薬品の「零売」を推奨するような広告が行われている旨の通報があ

ったことから、埼玉県加須保健所において立入調査を実施し、令和4年度通知の内容に即して「零売」を推奨するような広告表現を控えるように説明したに留まる。[REDACTED]」の側も当該要請に任意で応じており、実施態様は適切な行政指導の範囲内で行われている。

- b なお、原告らは薬事監視指導票の原本の開示を求めているが、埼玉県の運用上、指導票を交付する際には複写紙を用いて作成し、複写として記録した指導票についても原本として立会者に交付する。したがって、原告らが提出した甲第36号証に係る原本が、薬事監視指導票の原本書類に当たる(乙31の2)。

(イ) 「オオギ薬局」に対する行政指導について

- a 以下に述べるとおり、厚生労働省医薬局がオオギ薬局グループに対して行った行政指導は、適切な行政指導の範囲内で行われたものであるから、「執拗な行政指導」が行われたとして本件各通知に外部効果がある旨をいう原告らの主張を根拠づけるものではない。

すなわち、オオギ薬局グループは東京都内において「零売薬局」事業を展開していたところ、厚生労働省医薬局は、令和3年に医薬品等適正広告基準及び薬局医薬品通知に違反する医療用医薬品の販売や広告がされているとの通報があったことから、同年12月13日、オオギ薬局グループの代表者である扇柳創輔氏(以下「扇柳氏」という。)及び同グループ恵比寿店の代表である村上正樹氏と面談をした。同面談において、厚生労働省医薬局の担当者は、医薬品等適正広告基準に基づいて処方箋なしで処方箋医薬品以外の医療用医薬品を購入することができるといった趣旨の広告をしないよう求めた一方、飽くまで通知に基づく指導であり、法律違反ではないことをきちんと説明した上で、自分で診断することができない患者を守ることと、「零売」の仕組み自体は維持できるようにすることとの両立を図る観点から、

特定の医療用医薬品の名称が分かるような広告を控えるように指導したにすぎず(甲37・7ページ参照)、原告らが主張するような「処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売を規制するかのよう警告」(原告ら第3準備書面・8及び9ページ)をした事実はない。

また、厚生労働省医薬局は、上記面談後の令和4年3月、当該面談を踏まえたその後のオオギ薬局グループの広告活動の状況を確認するため、オオギ薬局グループと再度の面談を実施しており、その際、前回面談時に要請した点の改善が一切見られないことから改めて同趣旨の指導を実施したが、前回同様、医薬品等適正広告基準に基づいた任意の指導に留まり、オオギ薬局グループ側もその点を十分理解していた。その後、厚生労働省医薬局は、令和5年4月にも扇柳氏と面談を実施しているが、当該面談は、扇柳氏自身から「医薬品の販売制度に関する検討会」で参考人として発言をする機会が欲しい旨の希望があったことを受けて、当該検討会に向けた調整をするために面談をしたにすぎず、オオギ薬局グループに対する指導を行ったものではない。扇柳氏は、令和4年通知が出された直後に2回目の指導を受けて、「なぜ前回指導したことをやらないのか」などという「強圧的な」指導を受けた旨を述べるが(甲38・3ページ)、令和4年3月の面談時にはそもそも令和4年通知は発出されておらず、令和5年4月の面談も扇柳氏からの希望で検討会に向けた準備で面談しただけにすぎないのであるから、上記供述は信用性に乏しい。

- b なお、オオギ薬局グループは、前記の各行政指導を受けたにもかかわらず、同グループのホームページや経営する薬局の店頭看板等において、以下のように一般消費者を対象として、処方箋なしに処方箋医薬品以外の医療用医薬品を販売できることを積極的に広告していることを、念のため付言する。

- ① ホームページの検索結果の大見出しに「処方箋なしで病院の薬が買える零売薬局」と表示されるようにしている(乙32の1)。
- ② ホームページのトップページ等において、処方箋なしで医療用医薬品を購入できること、病院に行く時間がない人でも通えること、病院にかかるよりも値段が安く済む場合があること等を積極的に説明している(乙32の2)。
- ③ 店頭看板において、処方箋なしで医療用医薬品を購入できることを積極的に説明している(乙32の3)。

(3) 原告まゆみ薬局及び原告グランドヘルスのホームページに係る原告らの追加主張は理由がないこと

ア 原告らの主張

原告らは、原告まゆみ薬局及び原告グランドヘルスのいずれに関しても、ホームページ上で最も訴求したい事項は「処方箋がなくても処方箋医薬品以外の医療用医薬品を購入することができる」という点であったにもかかわらず、令和4年通知により、かかる表現を最小限にとどめざるを得なかったなどとして、「零売薬局」としての十分な広告ができないという具体的な不利益を受けている旨を種々主張する(原告ら第3準備書面・3ないし5ページ)。

イ 被告の反論

(7) 原告まゆみ薬局について

被告準備書面(2)第2の1(4)イ(15ないし17ページ)で詳細に述べたとおり、原告まゆみ薬局が、現に一般消費者を対象として、処方箋なしに処方箋医薬品以外の医療用医薬品を販売できることを積極的に広告していることは、客観的事実から明らかである(乙19)。

原告らは、原告まゆみ薬局のホームページにおいて、最も訴求したい事項であるとする「処方箋なしでお薬が買える」という記載が検索結果

の大見出しに出るように設定されているにもかかわらず(乙19の2)、
「検索結果として表示されるにすぎない」などと主張するが(原告ら第3
準備書面・3ページ)、原告まゆみ薬局のホームページを訪問したユーザ
ーは、かかる検索結果の大見出しを、ホームページを訪問する際の選択
材料にしていると考えられ、ホームページの作成者も、こうした選択材
料として使われることを想定して検索結果の大見出しを設定すると考え
られることからすれば(乙20参照)、積極的な広告の一部を構成するも
のであるといえる(なお、仮に上記設定を行ったのが前代表者であるとし
ても、原告まゆみ薬局の行為であることに変わりなく、原告まゆみ薬局
の現代表者もホームページ作成会社と相談してホームページの内容を変
更したことを自認しており(甲20)、ソースコードの変更が困難であっ
たなどの事情も見当たらないことからすれば、上記設定が残されたこと
については、原告まゆみ薬局の積極的な意思が反映されたとみるのが自
然である。)。

原告らの前記アの主張は、要するに、現在の広告と異なる広告内容等
が存在することをもって、現在の広告が最小限のものであるなどという
後付けの理屈を述べるに留まっており、その異なる広告内容等による広
告を実施しようとしたが令和4年通知によって妨げられたことを裏付け
る客観的資料は全く見当たらない。

したがって、原告らの前記アの主張は理由がない。

(イ) 原告グランドヘルスについて

- a 被告準備書面(2)第2の1(4)ウ(17ないし20ページ)で詳細に述
べたとおり、原告グランドヘルスが、現に一般消費者を対象として、
処方箋なしに処方箋医薬品以外の医療用医薬品を販売できることを積
極的に広告していることは、客観的事実から明らかである(乙21)。

原告らは、原告グランドヘルスのホームページに係るソースコード

を設定した時期は令和4年通知の発出以前である旨主張するが(原告ら第3準備書面・5ページ)、仮に原告らがいうように令和4年通知によって特定の広告表現を控えざるを得なくなったというのであれば、検索結果の大見出しという広告効果の高い箇所の表現を従前のままにしておくのは不自然であるから、原告らの上記主張は何らの確かな反論となっていない。

原告まゆみ薬局について述べたとおり、原告らの前記アの主張は、後付けの理屈を述べるに留まっており、異なる広告内容等による広告を実施しようとしたが令和4年通知によって妨げられたことを裏付ける客観的資料は全く見当たらない。

したがって、原告らの前記アの主張は理由がない。

- b なお、原告らは、店舗の立地や店舗前以外の看板等を種々挙げて、本件各通知があることによって積極的な広告が行えない旨主張するが(原告ら第3準備書面・6ページ)、これらの点については予算や物件の空き状況等、諸般の事情を総合的に鑑みて決定することが通常であると考えられるところ、本件各通知の発出により出店戦略等が制限されていることを裏付けるに足る主張、立証は一切ないから、原告らの上記主張は理由がない。

2 処方箋医薬品以外の医療用医薬品につき、薬局においては処方箋に基づく薬剤の交付が原則となることは、法令の趣旨を踏まえた解釈であること(原告ら第3準備書面第2に対する反論)

- (1) 薬局医薬品から薬局製造販売医薬品を除いた医薬品(＝医療用医薬品)は、薬剤師の判断により販売することができない医薬品であること

ア 原告らの主張

- (ア) 原告らは、「薬剤師が薬学・薬事衛生の専門家であること」からすれば、薬機法4条5項2号所定の「「薬局医薬品」には、医師等に加え、薬剤師

等の薬学・薬事衛生の専門家(のいずれか)によって対面による情報の提供や指導が行われることが必要な医薬品なども含まれるものと解すべき」であるとし、それが「薬機法の趣旨」に適合する解釈である旨主張する(原告ら第3準備書面・10ページ)。

(イ) また、原告らは、薬機法において処方箋医薬品に係る規制が別途定められていること(薬機法49条1項)を強調して、処方箋医薬品と処方箋医薬品以外の医療用医薬品を同じ「医療用医薬品」という括りで捉え直し、一律に処方箋に基づく交付が原則であるとするのは、「薬機法の趣旨を逸脱した、法律による行政の原則に反する違法な行政規則を創造するもの」であるなどと主張する(原告ら第3準備書面・10ページ)。

(ウ) さらに、原告らは、「薬局製造販売医薬品の規定は、薬局医薬品の法令上の規定内容を限定する趣旨の規定ではない」とし、薬局医薬品から薬局製造販売医薬品を除いた医薬品について「薬剤師の判断を原則として排除する根拠となるものではない。」との従前の主張を繰り返すようである(原告ら第3準備書面・10及び11ページ)。

イ 被告の反論

(ア) 原告らの前記ア(ア)の主張については、原告らが述べる「薬機法の趣旨」の意味するところが定かでない上、薬剤師が「薬学・薬事衛生の専門家」であるとされているからといって、それがいかなる理由で、薬剤師において薬局製造販売医薬品を除いた薬局医薬品の使用の判断が可能であるとの主張につながるのかも判然としない。

この点をひとまずおき、被告がこれまで繰り返し述べているとおり、薬機法の趣旨は、医薬品の安全性確保並びにその使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止等を目的とする点にあると解されるところ(1条参照)、薬局医薬品は、需要者(一般の生活者)の選択によって使用されるものでなく、その効能及び効果において人体に対する作用が著し

い、保健衛生上のリスクが高い医薬品として規定されている(薬機法4条5項2号ないし4号参照)。そして、薬剤師は、飽くまで「調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどる」職種であって(薬剤師法1条)、「医療及び保健指導を掌る」医師(医師法1条)や、「歯科医療及び保健指導を掌る」歯科医師(歯科医師法1条)とは異なり、患者の状態を把握し、診断を要する疾患に対する効能・効果を有する医療用医薬品を正しく選択することができる職種とは認められていない。これらのことからすれば、薬剤師において使用の判断が可能であり、自ら製造販売を行うことが特に認められた薬局製造販売医薬品を除き、薬剤師に対して薬局医薬品の使用の判断を認めることは、診断を要する疾患に対する効能・効果を有する医療用医薬品の選択を認めるに等しく、保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止等を目的とする薬機法の趣旨に反することが明らかといえる。

したがって、原告らの前記ア(ア)の主張は理由がない。

(イ) 次に、原告らの前記ア(イ)の主張についても、原告らのいう「法律による行政の原理」の意味するところが定かでないが(いわゆる「法律の留保」の原則をいうものと解した場合、被告が繰り返し述べているとおり、そもそも本件各通知は外部効果を有しない行政規則であり、法律の留保を必要とする行政活動には当たらない。)、要するに、薬機法49条1項が処方箋医薬品について特別の規制を設けている以上、これと処方箋医薬品以外の医療用医薬品を一括した「医療用医薬品」というカテゴリーを設けて一律の取扱いをすることは「薬機法の趣旨を逸脱」する旨を主張するようである。

しかしながら、そもそも処方箋医薬品に係る薬機法49条1項の規制は、「覚醒剤」や「麻薬製剤」、「放射性医薬品」のように、その成分等により保健衛生上のリスクが生じ得るものとして指定され、製剤としての

取扱い自体に関するリスクが高いものとして指定されているものであるから、かかる規制とは異なる観点から、処方箋医薬品と処方箋医薬品以外の医療用医薬品について共通の取扱いをすることが妨げられるものではない(被告準備書面(1)第1の4(3)・27及び28ページ、同(4)ウ・30ページ参照)。そして、前記(ア)で述べたとおり、医療用医薬品を薬剤師の判断により販売することができない医薬品であると解することは、薬機法の趣旨に整合するものであり、薬機法上、このような解釈を積極的に否定する根拠も見当たらない。

したがって、本件各通知による取扱いが「薬機法の趣旨を逸脱」する旨をいう原告らの前記ア(イ)の主張は理由がない。

(ウ) さらに、原告らの前記ア(ウ)の主張について、原告らは薬局製造販売医薬品に係る薬機法施行令3条の規定のみに着目するようであるが、前記(ア)で述べたとおり、被告は、需要者(一般の生活者)の選択によって使用されるものでなく、その効能及び効果において人体に対する作用が著しい、保健衛生上のリスクが高い医薬品として規定された薬局医薬品のうち、薬剤師において使用の判断が可能な医薬品としての類型(薬局製造販売医薬品)が特別に定められているという薬機法の仕組みを踏まえた主張をしているから、原告らの前記ア(ウ)の主張は、被告の主張を正解していない。

したがって、原告らの前記ア(ウ)の主張は理由がない。

(エ) 以上のとおり、原告らの前記アの主張にはいずれも理由がなく、薬局医薬品から薬局製造販売医薬品を除いた医薬品(＝医療用医薬品)は、薬剤師の判断により販売することができない医薬品である。

(2) 薬局医薬品から薬局製造販売医薬品を除いた医薬品(＝医療用医薬品)を処方する行為は、「医行為」に該当すること

ア 原告らの主張

(ア) 原告らは、最高裁令和 2 年決定が、ある行為が医行為に該当するか否かを判断する際には「当該行為の実情や社会における受け止め方等をも考慮する必要がある」と判示した点について、処方箋医薬品以外の医療用医薬品は比較的风险の低い医薬品であるとか、国民・市民のセルフメディケーションに係る権利に資するなどの従前の主張を繰り返し、かかる「零売行為の実情や社会における受け止め方等を考慮」すれば、「零売」は医行為には該当しない旨を主張するようである(原告ら第 3 準備書面・11 及び 12 ページ)。

(イ) また、原告らは、薬機法施行規則 158 条の 9 第 4 号等において、「必要に応じて、当該薬局医薬品に代えて他の医薬品の使用を勧めさせること」を薬剤師に行わせなければならない旨規定されていることについて、「薬剤師が、薬学の専門家として、患者の状態に応じて医療用医薬品の提供(零売)を選択することは、その専門的判断の範囲内である」とし、薬剤師の判断によって医療用医薬品を販売することは妨げられない旨主張するようである(原告ら第 3 準備書面・13 ページ)。

イ 被告の反論

(ア) 原告らの前記ア(ア)の主張について、確かに処方箋医薬品以外の医療用医薬品は、処方箋医薬品と比較すれば、その成分等に関しては比較的风险が低いといい得るものの、被告がこれまで繰り返し述べているとおり、そもそも医療用医薬品自体が、その効能及び効果において人体に対する作用が著しい、保健衛生上のリスクが高い医薬品として規定されているところ、その安全性が十分に確保されるためには、患者の健康状態に合わせて当該医薬品を使用することが適切か否かを判断することや、適切である場合に当該医薬品の一定の幅のある記載から適切な用法・用量を設定することが欠かせないのであるから、医薬品の有効成分等のみに着目する原告らの主張は理由がない。

また、原告らがセルフメディケーションに係る権利について述べる点は、かかる権利の内実が不明瞭であることはさておき、そもそも医療用医薬品を含む薬局医薬品自体、需要者(一般の生活者)の選択により使用されることが目的とされていないことからすれば、薬機法は、需要者(一般の生活者)に対し、かかる医薬品を自己の判断で選択する権利を認めていないといえる。

したがって、原告らの前記ア(ア)の主張は、その前提を誤るものであって理由がない。なお、「零売薬局」という業態において処方箋医薬品以外の医療用医薬品を販売する行為(「零売」)は、飽くまで、ごく限定的な一部の薬局が、過去10年程度という極めて最近の時期から事業展開を始めたサービスにすぎず、社会的実体・実情として我が国において広く国民に認知又は受容されているとはいい難く、この点は原告らや、日本零売薬局協会等の「零売薬局」事業者も自認している(乙28の1、乙33の1及び乙33の2)。かかる「実情や社会における受け止め方」に照らしても、「零売薬局」において処方箋医薬品以外の医療用医薬品を販売する行為が医行為に該当しないと解すべき事情は見当たらない。

(イ) 原告らの前記ア(イ)の主張については、前記(1)イ(ア)で述べたとおりである。すなわち、薬剤師は、患者の状態を把握し、診断を要する疾患に対する効能・効果を有する医療用医薬品を正しく選択することができる職種とは認められていないのであるから、「患者の状態に応じて医療用医薬品の提供(零売)を選択すること」は、明らかにその職能を超えるものである。

(ウ) したがって、原告らの前記アの主張はいずれも理由がない。

第3 結語

以上のとおり、本件広告等地位確認の訴えについて、原告らには確認の利益

が認められないから、いずれも速やかに却下されるべきである。

また、本件販売地位確認請求、本件各国賠請求、訴えの追加的変更申立書及び訴えの追加的変更申立書(2)記載の各請求にはいずれも理由がないから、原告らのこれらの請求はいずれも速やかに棄却されるべきである。

以 上